

予備独自問題R 4-24

(配点: 3)

月 日

月 日

違法収集証拠排除法則に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 違法に収集された証拠物の証拠能力については、刑事訴訟法に何らの規定も置かれていないので、この問題は、刑事訴訟法の解釈ではなく、憲法の解釈に委ねられている。
- イ. 違法収集証拠排除法則の目的は、法の適正な手続を保障し司法の廉潔さを保持することであって、将来における違法捜査を抑制することではない。
- ウ. 違法に収集された証拠物の証拠能力が否定されるかの判断に当たって、捜査の違法の程度は考慮されるが、当該証拠の重要性は考慮されない。
- エ. 違法に収集された証拠物の証拠能力が否定されるかの判断に当たって、捜査機関が当該証拠の押収までに行ったことは考慮されるが、押収後に行ったことが考慮されることはない。
- オ. 違法な逮捕に引き続く身体拘束中に覚醒剤使用の証拠となる尿を被疑者が任意提出した場合、逮捕が覚醒剤使用ではなく窃盗を理由とするものであれば、尿の証拠能力は否定されない。

ア 誤っている

本記述は、違法に収集された証拠の証拠能力の問題は、刑事訴訟法の解釈ではなく、憲法の解釈に委ねられているとしている点で、誤っている。

最判昭53.9.7（百選88事件）。判例は、「違法に収集された証拠物の証拠能力については、憲法及び刑訴法になんらの規定もおかれていないので、この問題は、**刑訴法の解釈に委ねられているもの**と解するのが相当であるところ、刑訴法は、『刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。』（同法1条）ものであるから、違法に収集された証拠物の証拠能力に関しても、かかる見地からの検討を要する」としている。

イ 誤っている

本記述は、違法収集証拠排除法則の目的は、将来における違法捜査を抑制することではないとしている点で、誤っている。

違法収集証拠排除法則については、①憲法31条、33条、35条の要求する適正手続の帰結として憲法上の法規範として導かれるとの理解、②司法機関への国民の信頼を確保すべきだという司法の廉潔性の観点から政策的に導かれるべきだとの理解、③捜査機関の将来の違法行為を抑止すべきだという抑止効の観点から政策的に導かれるべきだとの理解がある。判例がどの理解に立つかについて評価は分かれているが、最判昭53.9.7（百選88事件）は、「憲法31条が法の適正な手続を保障していること等にかんがみると、証拠物の押収等の手続に、憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるものと解すべきである」としており、少なくとも③抑止効の理解を否定するものではないといえる。したがって、違法収集証拠排除法則の目的には、将来における違法捜査を抑制すること含まれる。

ウ 誤っている

本記述は、違法に収集された証拠物の証拠能力が否定されるかの判断に当たって、当該証拠の重要性は考慮されないとしている点で、誤っている。

最判平15.2.14（百選90事件）。判例は、「本件覚せい剤〔注：覚醒剤〕及びこれに関する鑑定書については、その収集手続に重大な違法があるとまではいえず、その他、これらの証拠の重要性等諸般の事情を総合すると、その証拠能力を否定することはできない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、「排除相当性」の判断が裁量的、政策的判断を含むという前提に立てば、証拠の重要性を考慮要素とすることは妨げられるものではないということを挙げている。したがって、違法に収集された証拠物の証拠能力が否定されるかの判断に当たって、捜査の違法の程度のみならず、当該証拠の重要性が考慮されることはある。

エ 誤っている

本記述は、違法に収集された証拠物の証拠能力が否定されるかの判断に当たって、捜査機関が当該証拠の押収後に行ったことが考慮されることはないとしている点で、誤っている。

最判平15.2.14（百選90事件）。判例は、「本件逮捕には、逮捕時に逮捕状の呈示がなく、逮捕状の緊急執行もされてない……という手続的な違法があるが、それにとどまらず、警察官は、その手続的な違法を糊塗するため、……逮捕状へ虚偽事項を記入し、内容虚偽の捜査報告書を作成し、更には、

公判廷において事実と反する証言をしているのであって、本件の経緯全体を通して表れたこのような警察官の態度を総合的に考慮すれば、本件逮捕手続の違法の程度は、令状主義の精神を潜脱し、没却するような重大なものであると評価されてもやむを得ない」としており、逮捕後に生じた事情も考慮している。したがって、違法に収集された証拠物の証拠能力が否定されるかの判断に当たって、捜査機関が当該証拠の押収後に行ったことが考慮されることはある。

オ 誤っている

本記述は、逮捕が覚醒剤使用ではなく窃盗を理由とするものであれば、尿の証拠能力は否定されないとしている点で、誤っている。

最判平 15.2.14 (百選 90 事件)。判例は、司法警察官が、被告人甲を窃盗罪で逮捕すべく甲宅に赴いたが、あらかじめ発付されていた逮捕状を携行せず呈示を怠り、かつ逮捕状を携行したかのように捜査報告書を偽造し、その逮捕によって甲を身柄拘束し、そこで尿を任意提出させた(その後、尿の鑑定書を疎明資料として発付された搜索差押許可状などを用いて覚醒剤などを発見し、差し押さえた)事案において、一次証拠である尿(の鑑定書)の証拠能力について、先行する逮捕手続の違法の重大性を前提とした上で(肢エ解説参照)、「このような違法な逮捕に密接に関連する証拠を許容することは、将来における違法捜査抑制の見地からも相当でない」として証拠能力を否定している。先行手続の違法が適法な後行手続によって得られた証拠物の証拠能力に影響するかという問題について、過去の判例(最判昭 61.4.25、百選 89 事件)では、同一目的・直接利用の関係がみられる場合は、採尿手続の違法性について、先行手続の違法の有無・程度を十分考慮して判断するとの考え方が示されていた。これに対して、平成 15 年判決の事案は、窃盗罪の逮捕手続に違法があったところ、問題となる証拠は覚醒剤使用に関するものであるため、違法手続と証拠収集手続との関係は同一目的ではなく、直接利用の関係にあると評価できるか否かも微妙であるが、結論として証拠能力が否定されている。同判決のいう「密接に関連」とは、違法な先行手続のおかげで後の手続で証拠を獲得できたという因果性の有無・程度を意味するものと理解されている。したがって、違法な逮捕に引き続き身体拘束中に覚醒剤使用の証拠となる尿を被疑者が任意提出した場合、逮捕が覚醒剤使用ではなく窃盗を理由とするものであっても、尿の証拠能力が否定されることはある。

